

RECURSO CÍVEL Nº 5005522-05.2024.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

ADVOGADO(A): MARCOS PEREIRA CABRAL (OAB ES026246)

ADVOGADO(A): CARLOS ALBERTO SAMORA JUNIOR (OAB ES026142)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 25 de março de 2025.

5005522-05.2024.4.02.5006

500003661912 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5005522-05.2024.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de ação visando à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição mediante a averbação de períodos especiais não reconhecidos pelo INSS.

A r. sentença julgou procedente em parte o pedido, determinando a averbação dos períodos de **01/03/2003 a 15/10/2008, 01/11/2012 a 31/12/2017, 01/01/2018 a 30/09/2018 e 01/10/2018 a 30/11/2018** como especiais.

Recorreu a parte ré requerendo a reforma do julgado para não reconhecimento da especialidade do período laborado na função de frentista (**01/03/2003 a 15/10/2008**).

Recorreu a parte autora pugnando pelo reconhecimento do período de **01/05/2009 a 30/08/2011** como especial.

É o breve relatório. Passo aos fundamentos do voto.

VOTO

Inicialmente, quadra registrar que a definição e a comprovação da natureza especial de atividades para fins de cobertura previdenciária, após inúmeras alterações legislativas desde a edição da Lei n. 3.807, de 26 de agosto de 1960 que instituiu o benefício da aposentadoria especial, é feita da seguinte forma:

a) até o advento da Lei n. 9.032/1995 a comprovação do exercício de atividade especial deve ser feita por meio de cotejo da categoria profissional do segurado com a classificação prevista no Anexo do Decreto n. 53.831, de 25 de março de 1964, ou nos Anexos I e II do Decreto n. 83.080, de 24 de janeiro de 1979. Havia presunção absoluta de exposição aos agentes nocivos - salvo para ruído e calor, que exigem medição - para as profissões enquadradas. A jurisprudência permite o reconhecimento como tempo especial de atividades não enquadradas nos decretos, desde que comprovada a exposição aos agentes nocivos de forma habitual (TNU, Súmula n. 49 e Pedilef n. 200771950012920), por perícia (STJ, REsp n. 600.277; Súmula do extinto TFR n. 198);

b) após a edição da Lei n. 9.032/1995, não bastava mais ao segurado comprovar a atividade profissional. A partir de então, passou a ser necessário demonstrar que a atividade especial não era exercida de forma ocasional ou intermitente e que o segurado trabalhou exposto aos agentes nocivos pelo período equivalente ao exigido para a concessão da aposentadoria especial.

Em resumo, **até 28/04/1995**, data de entrada em vigor da Lei n. 9.032/1995, o segurado deve demonstrar o enquadramento de sua categoria profissional nos decretos mencionados ou provar, por perícia, que trabalhou de forma habitual, ainda que intermitente (Súmula nº 49 da TNU), sob condições especiais. **A partir de 29/04/1995**, passou a ter de comprovar o trabalho sob condições especiais, de forma habitual e permanente, pelo período cuja declaração como tempo especial pretendesse.

A comprovação do tempo de serviço em condições especiais de 29/04/1995 a 05/03/1997 era feita por meio dos formulários SB-40, DSS-8030 ou DIRBEN 8030. A partir de 06/03/1997, data de entrada em vigor do Decreto n. 2.172, de 5 de março de 1997, até 31/12/2003, passou a ser exigido laudo técnico e de 01/01/2004 em diante a comprovação é realizada mediante apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) (TNU, Processo n. 0000020-09.3801.7.07.4134).

Cumprado estabelecer que a comprovação do exercício de atividade em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do trabalhador **rege-se pela lei vigente à época da prestação do serviço** e não pela lei vigente à época da produção da prova, sob pena de retroatividade e violação ao direito adquirido.

Tal entendimento tem lastro na jurisprudência pátria, que vê na contagem de tempo de serviço em condições especiais um direito subjetivo que se incorpora ao patrimônio do sujeito à medida que a prestação de serviço é efetivada, tornando-se impassível de ser atacado por norma superveniente que torne mais dificultosa a sua prova sob pena de violação do direito adquirido protegido pela carta de princípios em seu art. 5º, XXXVI. Nesse sentido, vale transcrever o seguinte julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE RURAL EXERCIDA EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. ATIVIDADE URBANA EXERCIDA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. ART. 28 DA LEI 9.711/98. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SUPORTE FÁTICO DESSEMELHANTE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O tempo de serviço é disciplinado pela lei vigente à época em que efetivamente prestado, passando a integrar, como direito autônomo, o patrimônio jurídico do trabalhador. A lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do tempo de serviço não pode ser aplicada retroativamente, em razão da intangibilidade do direito adquirido. 2. Se a legislação anterior exigia a comprovação da exposição aos agentes nocivos, mas não limitava os meios de prova, a lei posterior, que passou a exigir laudo técnico, tem inegável caráter restritivo ao exercício do direito, não podendo ser aplicada a situações pretéritas.

(STJ - RESP 200200147709, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ Data 05/02/2007).

No mesmo sentido, o § 1º do art. 70 do Decreto nº 3.048/99 dispõe, *in verbis*, que “a caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob condições especiais obedecerá ao disposto na legislação em vigor na época da prestação do serviço”.

Assim, observa-se que os agentes nocivos químicos, físicos e biológicos considerados para fins de aposentadoria especial encontram-se previstos na legislação da época da atividade, a saber: a) **até 05/03/1997**, o Decreto n. 53.831/1964 e os Anexos I e II do Decreto n. 83.080/1979; b) **de 06/03/1997 a 06/05/1999**, o Anexo IV do Decreto n. 2.172/1997; c) **a partir de 07/05/1999**, o Anexo IV do Decreto n. 3.048, de 6 de maio de 1999 (Regulamento da Previdência Social). Esclareça-se, porém, que o rol de agentes nocivos não é taxativo, podendo o autor provar as condições especiais sob as quais trabalhou através de perícia (TNU 0008484-51.2015.4.01.3900).

Essas são as premissas gerais que, em conjunto com aquelas particulares exigidas pelo caso concreto, irão orientar o julgamento do mérito.

Pois bem. No caso concreto, observa-se que a r. sentença enquadrou como especial o período de **01/03/2003 a 15/10/2008** laborado pelo autor na função de **frentista**.

De acordo com a firme jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, **não é possível o enquadramento especial pelo simples registro da categoria profissional de frentista**, haja vista que a mesma não está elencada nos Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79. Nesse sentido:

TEMA 157 TNU- Tese firmada: **Não há presunção legal de periculosidade da atividade do frentista**, sendo devida a conversão de tempo especial em comum, para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, **desde que comprovado o exercício da atividade e o contato com os agentes nocivos por formulário ou laudo**, tendo em vista se tratar de atividade não enquadrada no rol dos Decretos n. 53.831/64 e 83.080/79. (Julgado em 11/09/2014)

EMENTA - PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. FRENTISTA. ALEGAÇÕES DIVERSAS DA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONHECIMENTO. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 157/TNU. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF. PENDENTE DE JULGAMENTO. PEDIDO ACONHECIDO EM PARTE, NA PARTE CONHECIDA PROVIDO. (...) 4. **Não é possível o reconhecimento como especial de período trabalhado como frentista, por mero enquadramento profissional com apresentação de registro em CTPS. Precedentes desta TNU, em representativo de controvérsia (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL 50095223720124047003, JUÍZA FEDERAL KYU SOON LEE, DOU 26/09/2014 PÁG. 152/227).** (...)

(TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 0005610-75.2010.4.01.3801, TAIS VARGAS FERRACINI DE CAMPOS GURGEL - DATA 21/11/2018)

Assim, mostra-se necessária a comprovação de efetiva exposição a agentes nocivos para o reconhecimento de atividade especial na função de frentista.

Analisando a documentação carreada aos autos, verifico que é possível o enquadramento do período supracitado uma vez que foi apresentado PPP (evento 15, PPP2) indicando a presença de agentes nocivos no ambiente de trabalho (gasolina, etanol e diesel), com os quais o demandante tinha contato no exercício de suas atribuições.

Ocorre que um dos compostos da gasolina é o **Benzeno, substância considerada cancerígena pela LINACH** (Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos), prevista na Portaria Interministerial MTE/MS/MPS nº 9/2014 e no Anexo IV do Decreto nº 3.048/99 como agente nocivo. Vale dizer que **em relação a tal agente é suficiente a comprovação de sua presença no ambiente de trabalho** para fins de reconhecimento da especialidade, **independentemente do nível de concentração ou da existência de EPI eficaz**. Veja-se a jurisprudência atual nesse sentido:

EMENTA - PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. AGENTES RECONHECIDAMENTE CANCERÍGENOS. GRUPO 01 DA LISTA NACIONAL DE AGENTES CANCERÍGENOS PARA HUMANOS - LINACH. ANEXO IV DO DECRETO Nº 3.048/99. REGISTRO NO CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE - CAS. REQUISITOS CONCOMITANTES. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE INDEPENDENTEMENTE DA UTILIZAÇÃO DE EPI/EPC EFICAZ. AGENTE NOCIVO TOLUENO. GRUPO 2A. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O incidente foi tempestivamente interposto, restando demonstrada a existência de divergência entre decisões sobre questão de direito material proferidas por Turmas Recursais da mesma região na interpretação da Lei. 2. **O Memorando-Circular Conjunto nº 2/DIRSAT/DIRBEN/INSS, de 23/07/2015, estabeleceu que "a utilização de Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC e/ou Equipamentos de Proteção Individual - EPI não elide a exposição aos agentes reconhecidamente cancerígenos, ainda que considerados eficazes".** 3. **Agentes "reconhecidamente cancerígenos" são aqueles constantes concomitantemente no Grupo 01 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - LINACH e no Anexo IV do Decreto nº 3.048/99, e que possuam registro no Chemical Abstracts Service - CAS.** 4. O agente químico tolueno não atende aos requisitos dispostos no Memorando-Circular, tendo em vista que não consta do Grupo 1 da LINACH, que contempla "agentes confirmados como carcinogênicos para humanos", mas sim no Grupo 2A ("agentes possivelmente carcinogênicos para humanos"). 5. **Tese firmada no sentido de que "os agentes reconhecidamente cancerígenos (em relação aos quais a utilização de Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC e/ou Equipamentos de Proteção Individual - EPI não elide a exposição aos agentes reconhecidamente cancerígenos, ainda que considerados eficazes) são aqueles constantes concomitantemente no Grupo 01 da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - LINACH e no Anexo IV do Decreto nº 3.048/99, e que possuam registro no Chemical Abstracts Service - CAS, o que não é o caso do agente nocivo tolueno, que está incluído no Grupo 2A".** 6. Incidente de uniformização conhecido e improvido.

(TRF-4 - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (TRU): 50038653420194047209 SC 5003865-34.2019.4.04.7209, Relator: MARINA VASQUES DUARTE, Data de Julgamento: 19/03/2021)

EMENTA - RECURSO ESPECIAL Nº 1938490 - RS (2021/0148216-9) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO NAIONAL DO SEGURO SOCIAL com respaldo na alínea a do permissivo constitucional contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO assim ementado (e-STJ fls. 267/269): PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. CRITÉRIO DOSPICOS DE RUÍDO. HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. ÓLEOS MINERAIS. AGENTES CANCERÍGENOS. UTILIZAÇÃO DE EPI. INEFICÁCIA RECONHECIDA. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA. REAFIRMAÇÃO DA DER. POSSIBILIDADE. TEMA 995 DO STJ. (...)5. A exposição aos óleos minerais enseja o reconhecimento do tempo como especial. 6. **Os hidrocarbonetos aromáticos são compostos de anéis benzênicos, ou seja, apresentam benzeno na sua composição, agente químico este que integra o Grupo 1 (agentes confirmados como cancerígenos para humanos) do Anexo da Portaria Interministerial MPS/MTE/MS nº 09-2014, e que se encontra devidamente registrado no Chemical Abstracts Service (CAS) sob o nº 000071-**

43-2.7. Demonstrado, pois, que o benzeno, presente nos hidrocarbonetos aromáticos, é agente nocivo cancerígeno para humanos, a simples exposição ao agente (qualitativa) dá ensejo ao reconhecimento da atividade especial, qualquer que seja o nível de concentração no ambiente de trabalho do segurado. 8. Em se tratando de agente cancerígeno, a utilização de equipamentos de proteção individual é irrelevante para o reconhecimento das condições especiais da atividade. 9. Para a caracterização da especialidade, não se reclama exposição às condições insalubres durante todos os momentos da prática laboral, sendo suficiente que o trabalhador, em cada dia de labor, esteja exposto a agentes nocivos em período razoável da jornada, salvo exceções (periculosidade, por exemplo). 10. A habitualidade e permanência hábeis aos fins visados pela norma - que é protetiva - devem ser analisadas à luz do serviço cometido ao trabalhador, cujo desempenho, não descontínuo ou eventual, exponha sua saúde à prejudicialidade das condições físicas, químicas, biológicas ou associadas que degradam o meio ambiente do trabalho. (...)

(STJ - REsp: 1938490 RS 2021/0148216-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJe 17/08/2021)

Assim, não merece prosperar o recurso do réu.

Tampouco merece guarida o recurso do autor, visto que em relação ao período de **01/05/2009 a 30/08/2011**, não há registro da presença de agentes nocivos no ambiente de trabalho do autor de forma habitual.

Importa dizer que, apesar de tratar-se do mesmo empregador, houve **alteração na descrição das atividades** desempenhadas pelo demandante, segundo o PPP apresentado (evento 15, PPP3), não sendo mais prevista a exposição habitual e permanente aos agentes nocivos apontados no período anterior.

Desta feita, entendo que as partes não apresentaram nenhum argumento ou impugnação capaz de modificar o juízo de valor firmado em primeira instância e ratificado por esta Relatoria, devendo ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

INSS isento de custas processuais. Condeno o réu ao pagamento da verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor condenação, nos termos do art. 55, *caput*, da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 1º da Lei nº 10.259/2001. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, se mantidas as condições de miserabilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos nos termos do §3º do artigo 98 do novo CPC.

Ante o exposto, voto por **CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos**, nos termos da fundamentação supra.